

1501602-66.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... transportava para fins de tráfico. Após breve resistência do denunciado, os policiais o dominaram e o prenderam em flagrante delito. A quantidade de droga evidenciou sua inequívoca destinação ao tráfico. Diante de tudo quanto exposto, a Ilustre Representante do Ministério Público DENUNCIOU a Vossa Excelência WESLEY LIMONGI como incurso(s) no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06. O acusado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501602-66.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2283965/2021 - 05º D.P. PIRACICABA, 20885987 - 05º D.P. PIRACICABA, 1186/21/528 - 05º D.P. PIRACICABA, 2283965 - 05º D.P. PIRACICABA, 2283965/2021 - 05º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY LIMONGI

Réu Preso

Contr. nº 2021/001117

Aos 17 de janeiro de 2022, às 15:00 horas, por meio de audiência virtual da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr. José Eduardo de Souza Pimentel foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu WESLEY LIMONGI (preso CDP Piracicaba). Presente o defensor Dr(a). Dr. Sebastião Zinsly. Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: PM Marcello de Lucas Bertão e PM RAFAEL ALDO VICENTINI. Presente(s) a(s) testemunha(s) de defesa: Irineu Luis Andriotta, Adriana Aparecida Biesse da Silva e Fatima Regina de Souza. Pela M.M Juíza de Direito foi explicado que, diante da restrição de acesso ao prédio do Tribunal de Justiça, em razão da pandemia do COVID-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e orientação do Comunicado CG nº 284/2020, a audiência será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft.

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com o(a) acusad(a) e todos os presentes foram retirados da sala, inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa.

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os

trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s), primeiramente as comuns (PM Rafael e PM Marcello), após a defesa (Irineu) e em seguida o interrogatório do réu foi captado e gravado em áudio e vídeo.

Dada a palavra a Defesa foi dito que desistia das oitivas da(s) testemunha(s)

Adriana e Fatima, o que foi homologado pelo(a) MM. Juiz(a).

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a).WESLEY

LIMONGI, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no art. 33 da Lei de Drogas. De acordo com a denúncia, no dia 18 de outubro de 2021, por volta das 11 horas e 30 minutos, na rua Nilo Peçanha nº 430, nesta cidade e comarca, o réu transportava no veículo Citroën C3 GLX 1.4Flex de placas EVB 8971

(Piracicaba/SP), para fins de tráfico e consumo de terceiro, 5 invólucros plásticos do tipo "filme", na forma de tijolos, contendo fragmentos vegetais ressequidos, nos quais se constatou a presença do THC, com massa líquida de 3.501,9g, bem como 5 invólucros plásticos do tipo "filme", na forma de tabletes, contendo fragmentos vegetais ressequidos, nos quais se constatou a presença do THC, com massa líquida de 468g da substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O processo teve trâmite regular, conforme se observa a fls.

175, 193 e 210. A materialidade delitativa foi comprovada pelo auto de exibição e

apreensão de fls. 9/11; fotografia de fls. 10/11; laudo de constatação de fls.

13/16; laudo do exame químico-toxicológico de fls. 127/129; laudo pericial de fls.

117/126; e BOPM de fls. 167/171. A autoria também foi determinada na prova oral

coligida. Os policiais militares Vicentini e Bertão contaram, em uníssono, que foram informados de que o veículo Citroën C3GLX 1.4 de placas EVB 8971 estava sendo utilizado para a distribuição de drogas nas "biqueiras" do bairro Santa Terezinha.

Em diligências pelo bairro, a patrulha avistou o tal veículo e deu ordem de parada

a seu condutor (o denunciado WESLEY), para a devida fiscalização. O acusado não

atendeu à ordem de parada e empreendeu fuga, sendo perseguido por diversas ruas e

bairros da cidade, até que, na rua Nilo Peçanha, perdeu o controle de seu conduzido

e se envolveu em acidente de trânsito (laudo de fls. 119/126). Os PMS se

aproximaram do veículo imobilizado e constataram a existência de uma caixa de

papelão sobre o banco traseiro, na qual se encontravam os tijolos e os tabletes de

maconha já mencionados. O PM Vicentini disse, em acréscimo, que apurou com o pai do

acusado que o veículo, embora tenha sido "tirado" no nome dele (genitor), pertencia

ao acusado. O réu é conhecido dos meios policiais e, as informações precedentes,

deram conta de que WESLEY era responsável pelo abastecimento das biqueiras do

bairro. O PM Bertão, corroborando a narrativa do colega, estimou que a perseguição

prosseguiu por cerca de 5 ou 8 Km. Explicou que os pais do réu compareceram na

Delegacia e informaram que o veículo pertencia ao acusado, embora registrado em

nome do pai dele. Irineu, empregador do acusado, nada sabia sobre os fatos. Disse

que o réu tinha um Citroën à época dos fatos. Interrogado, WESLEY admitiu o fato

criminoso. Falou que entregaria as drogas na Praça do Caxambu. Tem antecedentes

criminais por roubo. Finda a instrução, a prova reclama a condenação do réu. Tanto

na fase informativa quanto em Juízo, os PMS, cujos relatos se presumem verdadeiros

e legítimos, confirmaram a apreensão da expressiva quantidade de droga transportada

réu. Sobre o tema: (...) registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor

probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se

mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. (AgRg no HC

620.668/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe

18/12/2020).

Assim, a condenação é de rigor. Na aplicação da pena, verifica-se que quantidade de droga reclama o aumento da pena-base. Conforme dispõe o artigo 42 da Lei

11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o

previsto no art. 59 do Código Penal, dentre outras circunstâncias, a quantidade de drogas, a personalidade e a conduta social do agente. Em atenção à disposição legal, o E. Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, tem reconhecido como adequado em hipóteses similares o aumento da pena-base na fração de 1/5. Confira-se: Ação Penal – Tráfico de entorpecentes – Sentença condenatória – Apreensão de maconha e cocaína – Comprovação de autoria e materialidade – Depoimentos prestados pelos policiais militares de maneira coesa e que merecem crédito diante do contexto probatório – Versão apresentada pelo réu que restou isolada nos autos – Dosimetria: Primeira fase – Pena-base fixada 1/5 acima do mínimo legal – Segunda fase – reincidência do réu, elevando a pena na fração de 1/6 – Terceira fase – Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena. Regime fechado que se mostra adequado para o cumprimento inicial da reprimenda – Pena privativa de liberdade que não pode ser substituída pela restritiva de direitos – Dicção do disposto no art. 44, I e II, CP (TJSP; Apelação Criminal 1501026-87.2019.8.26.0617; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020). Sem grifos no original. Ainda na primeira fase, de se observar que o réu é duplamente reincidente. Assim, uma das condenações deve valorada como Maus antecedentes, e implicar novo aumento da pena-base. Outra, considerada para fins de reincidência, ensejando novo aumento da pena. Essa orientação tem sido adotada pelo STJ. Confira-se: As hipóteses de reincidência específica ou multirreincidência podem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6, para a agravante de reincidência. (AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020; sem grifos no original). A jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos Maus antecedentes. (HC 543.962/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019). O réu não tem direito ao benefício do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois, conforme F.A. e certidões criminais (fls. 38/46), trata-se de indivíduo que desde a adolescência se dedica à prática de crimes. É duplamente reincidente em roubo majorado. Tratando-se de indivíduo que faz do crime seu meio de vida, de rigor a fixação de regime inicial fechado. Esta é a orientação do STJ que, em caso semelhante ao dos autos, assim decidiu: Em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de apelado reincidente e possuidor de Maus antecedentes, não há falar em ilegalidade na fixação do regime fechado, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b" e § 3º, do Estatuto Repressor. Aplicação, a contrário sensu, da Súmula 269/STJ. (HC 557.198/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Sem grifos no original. No mesmo sentido: Sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (Maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ. (AREsp 1707256, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 03/08/2020, DJe 05/08/2020). Sem grifos no original. Por derradeiro, de rigor o perdimento do veículo utilizado para transportar a droga. Nesse sentido: É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (RE 638491, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 17/05/2017, Publicação: 23/08/2017). Pelo exposto, requer-se a procedência da presente ação penal, com a decretação da perda do veículo de placas EVB-8971. Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). WESLEY LIMONGI, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vem, muito respeitosamente à presença deste juízo, por meio de seu defensor constituído, com fulcro no artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal apresentar a presente. ALEGAÇÕES FINAIS POR MEMORIAIS. Pelos fatos e fundamentos que passa a expor: Da ausência de

justa causa à ação penal “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 18 de outubro de 2021, por volta das 11 horas e 30 minutos, na rua Nilo Peçanha nº 430, nesta cidade e comarca, WESLEY LIMONGI, qualificado a fls. 5, transportava no veículo Citroën C3 GLX 1.4 Flex de placas EVB 8971 (Piracicaba/SP), para fins de tráfico e consumo de terceiro, 5 invólucros plásticos do tipo “filme”, na forma de tijolos, contendo fragmentos vegetais ressequidos, nos quais se constatou a presença do THC, com massa líquida de 3.501,9g, bem como 5 invólucros plásticos do tipo “filme”, na forma de tabletes, contendo fragmentos vegetais ressequidos, nos quais se constatou a presença do THC, com massa líquida de 468g da substância entorpecente (cf. laudo de exame químico-toxicológico de fls. 127/129), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta, o denunciado estava atuando no tráfico de drogas na região da Comunidade Portelinha, sendo responsável pelo armazenamento de entorpecentes, instrumentos e materiais para fracionamento e embalo de crack e maconha. Apurou-se que policiais militares foram informados de que o veículo Citroën C3 GLX 1.4 Flex de placas EVB 8971 estava sendo utilizado para a distribuição de drogas nas “biqueiras” do bairro Santa Terezinha. Na data dos fatos, a patrulha composta pelos PMs Vicentini e Bertão avistou o tal veículo e deu ordem de parada a seu condutor (o denunciado WESLEY), para a devida fiscalização, atividade típica de polícia preventiva. WESLEY não atendeu à ordem de parada e empreendeu fuga, sendo perseguido por diversas ruas e bairros da cidade, até que, na rua Nilo Peçanha, perdeu o controle de seu conduzido e se envolveu em acidente de trânsito (laudo de fls. 119/126). Os PMs se aproximaram do veículo imobilizado e constataram a existência de uma caixa de papelão sobre o banco traseiro. Nessa caixa se encontravam os tijolos e os tabletes de maconha já discriminados, que o denunciado transportava para fins de tráfico. Após breve resistência do denunciado, os policiais o dominaram e o prenderam em flagrante delito. A quantidade de droga evidenciou sua inequívoca destinação ao tráfico.x

Diante de tudo quanto exposto, a Ilustre Representante do Ministério Público DENUNCIOU a Vossa Excelência WESLEY LIMONGI como incurso(s) no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06. O acusado vem em juízo ser confesso, informa que estava passando por muitas dificuldades financeiras com sua família, não estava conseguindo emprego, vendo sua filha passando fome, com o desespero em ver aquilo quase todo dia acontecendo, acabou aceitando fazer uma entrega de entorpecente, onde receberia R\$500,00 (quinhentos reais), mas não deu certo, além de perder a droga que terá que pagar por ela, ainda deixou sua família passando por dificuldades, sua esposa neste presente voltou morar com sua mãe para sustentar sua filha, ainda afirma que devido a este novo vírus que vem se alastrando na população acabou ficando sem emprego, e que o traficante lhe ofereceu R\$500,00 para que pudesse levar a droga em determinado local em Santa Terezinha, e fazendo isso sabendo da ilicitude mas precisava de dinheiro para poder sustentar sua família tendo em vista possuir filha menor de idade Ana Vitória de três anos, e por ser pai, em seu desespero, acabou aceitando do traficante aquele dinheiro para poder fazer a entrega. Na data dos fatos estava indo até o Bairro Vila Sonia entregar o entorpecente, contudo ao deparar com uma viatura ficou assustado por estar com as drogas, onde os policiais perceberam sua conduta; teve ordem de parada e o acusado não obedeceu, tendo perseguição, quando em uma curva ao lado do terminal de ônibus acabou entrando com a roda do veículo em um buraco enorme, sendo certo que o veículo foi completamente danificado sem possibilidade de rodar. Ocorre Excelência, que após o veículo parar, um dos policiais que estava nas diligências pegou o acusado pelo cabelo e puxou para fora do veículo e começaram a espancá-lo, e foi anexado por esta defesa o vídeo demonstrando que os policiais espancaram o acusado. Ainda ao mesmo tempo em que estava ocorrendo o espancamento um dos policiais veio e disse que encontrou drogas dentro do veículo. Segundo informações, que os policiais apenas apresentaram drogas na delegacia, não houve perícia no local do acidente, informando que a droga realmente estava dentro do veículo, ou se foram feitas perícias no veículo com algum vestígio de drogas. Cumpre ressaltar que o acusado não é traficante, É TRABALHADOR, TAMBÉM TEM RESIDÊNCIA FIXA, reincidente genérico. Ocorre Excelência, que o acusado nunca passou por situação parecida e afirma que nunca precisou vender drogas, mas já cometeu um delito de roubo, possui família, emprego fixo, residência

fixa e reside no distrito de culpa, com idade de 30 anos, possui bons antecedentes e nunca foi preso e nem apreendido quando menor de idade. O Acusado nunca traficou em sua vida, nem tampouco vendeu a quem quer que seja, qualquer tipo de droga, pois o acusado é reincidente genérico e não específico com idade de 30 anos, porém não existe nos autos de prisão qualquer prova de que o acusado seja traficante. Nota-se que não houve denúncia de que o acusado estava vendendo ou traficando, por ocasião de praxe os policiais resolveram abordá-lo em seu veículo, segundo os policiais por ter recebido informações de que Wesley estaria transportando drogas. É essencial que a parte autora consiga apresentar, desde a denúncia, um caderno de provas minimamente seguro, idôneo e capaz de dar suporte aos relatos dos policiais. Nesse sentido: "A Peça acusatória deve vir acompanhada com o mínimo embasamento probatório apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a efetiva realização do ilícito penal por parte dos denunciados. "Se não houver um lastro probatório mínimo a respaldar a denúncia, de modo a tornar esta plausível, não haverá justa causa a autorizar a instauração da persecutio criminis (Precedentes da Corte Especial e da Turma)" (STf, RHC 19166 / Rf, 5.ª Turma, Relator Ministro FELLX FISCHER, Df 20/11/2006 p. 342.). Como é sabido, o Direito Penal não se coaduna com suposições, sendo vedado o dolo in re ipsa. Frise-se, ainda, que nenhum ato concreto de traficância fora presenciado pelos milicianos. Podemos observar quanto a inquirição do CONDUTOR E PRIMEIRA TESTEMUNHA RAFAEL ALDO VICENTINI, RG 42236947 - Policial QUE SOU POLICIAL MILITAR E NA DATA DE HOJE ESTAVA DE SERVIÇO COM O POLICIAL BERTÃO E RECEBEMOS INFORMAÇÕES ANÔNIMAS DANDO CONTA QUE UM VEÍCULOMARCA CITROEN, MODELO C3, PLACAS EVB-8971 ESTARIA VINDO DO BAIRRO SÃO JORGE TRANSPORTANDO DROGAS PARA SER DISTRIBUIDAS NO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE, SENDO ASSIM FAZENDO PATRULHAMENTO OBJETIVANDO LOCALIZAR TAL VEÍCULO, NA RUA SÃO PEDRO, BAIRRO PQ PIRACICABA AVISTAMOS O VEÍCULO MENCIONADO NA DENÚNCIA, DEMOS ORDEM DE PARADA, CONTUDO, O CONDUTOR NÃO ACATOU E FUGIU POR DIVERSAS RUAS E BAIRROS, FOI SEGUIDO E NA RUA NILO PEÇANHA. NO BAIRRO VILA SÔNIA, O CONDUTOR PERDEU O CONTROLE DO VEÍCULO CHOCANDO-SE CONTRA UM MURO DE PROTEÇÃO; QUE O CONDUTOR ACABOU SENDO ABORDADO, APÓS TER SIDO NECESSÁRIO O USO DE FORÇA FÍSICA, E IDENTIFICADO COMO WESLEY LIMONGI ; QUE O MESMO FOI SUBMETIDO A UMA REVISTA PESSOA E ENCONTRADO EM SEU PODER A QUANTIA DE R\$ 30,00, PORÉM, NO INTERIOR DO VEÍCULO, SOBRE O BANCO TRASEIRO HAVIA UMA CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 05 TIJOLOS DE MACONHA E CINCO PORÇÕES MENORES DO MESMO ENTORPECENTE,; QUE QUESTIONADO A RESPEITO DA DROGA, WESLEY APENAS ASSUMIU A PRPRIEDADE E NÃO DEU OUTRAS INFORMAÇÕES. QUE FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO MESMO E CONDUZIDO ATÉ ESTA DELEGACIA DE POLÍCIA, PORÉM, ANTES O MESMO FOI ENCAMINHADO AO PRONTO SOCORRO DA VILA SÔNIA, ONDE FOI MEDICADO DEVIDO A UMA LESÃO NA CABEÇA QUE SOFREU QUANDO DA ABORDAGEM, JÁ QUE FOI NECESSÁRIO O USO DE FORÇA FÍSICA MODERADA PARA CONTÊ-LO, POIS O AUTOR AO CAIR O MESMO FICOU DEITADO COM BARRIGA PARA BAIXO E COM OS BRAÇOS CONTRAÍDO SOB O CORP O E NÃO SABENDO O QUE O MESMO TINHA NAS MÃOS, PODENDO ATÉ MESMO SER UMA ARMA DE FOGO OU ARMA BRANCA FOI DADO ALGUNS GOLPES COM OBJETIVO DE VIRÁ-LO E SOLTAR O QUE ESTAVA SEGURANDO, QUE NA VERDADE ERA UMA CHAVE ; QUE FOI USADO ALGEMAS PARA EVITAR POSSIVEL FUGA E PRESERVAR A SEGURANÇA DE TODOS ENVOLVIDOS; QUE SEGUNDO INFORMAÇÕES DO PRÓPRIO WESLEY O VEÍCULO CITROEN É DE SUA PROPRIEDADE. QUE FOI REQUISITADO EXAME PERICIAL E O PERITO JEFERSON SE FEZ PRESENTE NO LOCAL. NADA MAIS. O que nos estranha que o policial disse que o acusado estava de bruços, o que dava a entender estava com arma, mas nas imagens apresentava pela defesa em momento algum o acusado estava de bruços, essa narrativa dos policiais, é para se isentar da grave agressão causada pelos policiais contra o acusado. DA CONFISSÃO O réu foi denunciado pelo digno membro do MP, como incurso no artigo 33, caput, inciso II, da Lei nº 11.343/06. Quanto ao réu, vale ressaltar que é réu confesso, perante este Juízo, o que deve ser levado em conta por V. Exa. Contudo, há considerações a serem feitas acerca da aplicação da pena. Cumpre salientar que, por se tratar de direito subjetivo do agente, a confissão espontânea é causa obrigatória de diminuição de pena. Segundo o artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, são causas de diminuição da pena: "Artigo 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: ... Inciso III - ter o agente: ... d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime". Conforme posicionamento dos nossos Tribunais.

STJ - RECURSO ESPECIAL Resp 435430 MS 2002/0056953-9 (STJ) Data de publicação: 18/12/2006. Ementa: RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE. OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento pacificado no âmbito deste Tribunal, configura-se a confissão espontânea tão-somente pelo reconhecimento em Juízo da autoria do delito, sendo irrelevante que, preso em flagrante, não tenha restado outra alternativa para o agente. 2. Recurso conhecido e provido para, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, redimensionar a pena imposta. Com efeito, para a jurisprudência, a espontaneidade é o requisito fundamental para a concessão da redução, sendo certo que a confissão é considerada atenuante preponderante sobre as agravantes, ante a sua importância para a convicção do Juiz. Em todas as hipóteses relacionadas no inciso III do artigo 65 do Código Penal, a redução é obrigatória, observando-se, obviamente, o mínimo e o máximo da pena prevista. Nesse sentido, é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual: "Entre a circunstância subjetiva favorável ao acusado e a objetiva contrária, deve prevalecer aquela". Além da atenuante acima invocada, é necessário destacar quanto a sua primariedade genérica, uma vez que nunca praticou crime de tráfico anteriormente, assim sendo, goza ele de idoneidade moral perante a sociedade e este juízo, pois houve confissão espontânea do crime. Assim prevalece o entendimento dos nossos Tribunais a este respeito: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL - DECRETO CONDENATÓRIO - RECURSO DA DEFESA PLEITEANDO: ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA DE PROVAS OU, ALTERNATIVAMENTE, QUE A CARGA PENAL SEJA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL E, COM AS ATENUANTES DA PRIMARIEDADE E DOS BONS ANTECEDENTES E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - INSUBSISTÊNCIA RECURSAL - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - DOSIMETRIA - DUAS MAJORANTES - EXASPERAÇÃO DO AUMENTO DA PENA SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA - PENA REFORMADA, DE OFÍCIO, PARA REDUZIR O AUMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PLEITO DE ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS JÁ ARBITRADOS NA SENTENÇA - VALOR QUE SE NÃO AFIGURA CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, COM REFORMA DA DOSIMETRIA, DE OFÍCIO. "(. . .) No crime de roubo o fato da vítima reconhecer o agente com firmeza e determinação, constitui prova suficiente para condenação, mormente quando coerente com o conjunto probatório produzido" (TJPR - Ap. Crim. 0595380-0 - Londrina - 5ª C.Crim. - Relª Des. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira - Unânime - j. 05/11/2009). "Habeas Corpus. Penal. Homicídio qualificado. Existência de circunstância judicial desfavorável. Pena-base fixada acima do mínimo legal. POSSIBILIDADE. Fundamentação válida. Utilização da qualificadora sobejante para elevar a pena-base. Admissibilidade. (STJ - HABEAS CORPUS: HC 96236 MS 2007/0291719-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Julgamento: 14/05/2008, Órgão Julgador: T5). Presentes as atenuantes, a pena a ser cominada ao acusado deve ser a mínima legal. Diante o exposto requer: I - Caso entenda pela condenação do denunciado, o que não se espera, requer a aplicação da pena no mínimo legal, com a devida aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, analisando as circunstâncias pessoais favoráveis do denunciado (artigo 59, inciso IV, do Código Penal) e conversão em penas restritivas de direitos, de acordo com o artigo 44 do Código Penal, posto que o denunciado preenche todos os requisitos. II - Em caso de condenação, a aplicação do art. 59 da Lei 11.343/06 c/c 283 do Código de Processo Penal, somado aos princípios da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal), entendimento da prisão como última ratio, Lei 12.403/11 (medidas cautelares diversas da prisão), pelos efeitos negativos do cárcere, requisitos favoráveis do denunciado (primário, residência fixa, trabalho lícito), para que possa recorrer ainda em liberdade, sendo o caso. III - Por fim, caso Vossa Excelência decida pela condenação, que reconheça a circunstância atenuante estabelecida no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, bem como a primariedade do agente, de forma a ser fixada a pena no mínimo legal estabelecido. Nestes termos, pede deferimento. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir: Vistos, WESLEY LIMONGI, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 18 de outubro de 2021, por volta das 11,30 horas, na rua Nilo Peçanha nº 430, nesta cidade e comarca, transportava no veículo Citroën C3 GLX 1.4 Flex de placas EVB 8971 (Piracicaba/SP), para fins de tráfico e consumo de terceiro, 5 invólucros plásticos do tipo "filme", na forma de tijolos, contendo fragmentos vegetais ressequidos, nos quais se constatou a presença do THC, com massa líquida de 3.501,9g, bem como 5 invólucros plásticos do tipo "filme", na forma de tabletes, contendo fragmentos vegetais ressequidos, nos quais se constatou a presença do THC, com massa líquida de 468g da substância entorpecente (cf. laudo de exame químico-toxicológico de fls. 127/129), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que policiais militares foram informados de que o veículo Citroën C3 GLX 1.4 Flex de placas EVB 8971 estava sendo utilizado para a distribuição de drogas nas "biqueiras" do bairro Santa Terezinha.

Narra ainda que, na data dos fatos, a patrulha composta pelos PMs Vicentini e Bertão avistou o tal veículo e deu ordem de parada a seu condutor (o acusado WESLEY), para a devida fiscalização, atividade típica de polícia preventiva. WESLEY não atendeu à ordem de parada e empreendeu fuga, sendo perseguido por diversas ruas e bairros da cidade, até que, na rua Nilo Peçanha, perdeu o controle de seu conduzido e se envolveu em acidente de trânsito (laudo de fls. 119/126). Os PMs se aproximaram do veículo imobilizado e constataram a existência de uma caixa de papelão sobre o banco traseiro. Nessa caixa se encontravam os tijolos e os tabletes de maconha já discriminados, que o réu transportava para fins de tráfico.

Narra, ainda, que, após breve resistência do réu, os policiais o dominaram e o prenderam em flagrante delito.

Conclui a denúncia que a quantidade de droga evidenciou sua inequívoca destinação ao tráfico.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 175). Defesa preliminar apresentada às fls. 193/200. Após, a denúncia foi recebida (fls. 210/211) e o réu foi citado às fls. 250.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela parte e uma arrolada pela defesa. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade do delito.

A Defesa pediu a absolvição, por falta de provas.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede.

Autoria e materialidade do delito estão comprovadas pelos seguintes elementos:

- boletim de ocorrência de fls. 06/08 e BO/PM de fls. 167/171;
- auto de exibição e apreensão de fls. 09/11;
- laudo de constatação de fls. 13/14 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 185/187 c.c. fls. 186/188, com resultados positivos para tetrahidrocanabinol (THC) em relação às substâncias apreendidas;
- laudo pericial do local e do veículo apreendido (fls. 119/126) com a descrição do local do acidente e a anotação de que o veículo apresentava danos de aspecto recente relacionáveis com o objetivo da perícia;
- prova oral que, a seguir, será analisada.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 05), o réu não se manifestou sobre as drogas apreendidas. Apenas alegou que foi agredido pelos policiais militares e que seu advogado estava com as imagens das agressões, as quais seriam apresentadas à Autoridade Policial. Interrogado em juízo (gravação), confessou o crime. Disse que, no dia dos fatos, estava transportando as drogas descritas a denúncia, com intuito de entregá-las no bairro Caxambu. Disse que recebeu a proposta de um rapaz de nome Marcos e que aceitou fazer o "serviço" em troca de R\$ 500,00, por estar em dificuldades financeiras. Pegou a droga no Parque Piracicaba e iria entregar a uma pessoa que estaria com um veículo Corolla na praça do Parque Caxambu. Disse que trafegou duas

ruas e logo foi interceptado pela polícia. Ao receber a ordem de parada, entrou em desespero e fugiu, acelerando até que o carro quebrou e foi obrigado a parar. Neste momento, os policiais o tiraram do carro e o agrediram querendo saber quem havia lhe dado a droga. Foi levado para o PS no bairro Vila Sônia onde recebeu atendimento médico e depois foi encaminhado à delegacia.

A confissão foi corroborada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase informativa (fls. 03) e sob o crivo do contraditório (gravação), o policial militar Rafael Aldo Vicentini declarou que, na data dos fatos, estava em serviço com o policial Bertão quando receberam informação de que um veículo marca Citroen, modelo C3, placas EVB-8971 conduzido pelo réu (o denunciante forneceu não só o prenome, mas também o sobrenome dele), pessoa já conhecida nos meios policiais por envolvimento em crimes, estava vindo do bairro São Jorge em direção ao bairro Santa Terezinha, fazendo o transporte drogas para serem ali distribuídas. Disse que já recaíam diversas denúncias contra o réu por essa infração, as quais eram feitas por pessoas do bairro. Diante desse contexto, esperaram-no na saída da rodovia que dá acesso ao bairro São Francisco e se depararam com tal veículo quando ele entrou na Rua São Pedro, bairro Parque Piracicaba. Deram ordem de parada ao réu, seu condutor, com sinais sonoros e luminosos, mas ele não a acatou e fugiu por diversas ruas e bairros, dirigindo de modo a colocar em risco a vida e integridade física de outros condutores e transeuntes. Acompanharam-no até que, na Rua Nilo Peçanha, quebrou a barra de direção do veículo e o réu precisou parar. Ao descer do veículo, ele empreendeu fuga a pé e o acompanharam até que o alcançaram. Foi necessário o uso de força física para abordá-lo, pois ele resistiu à abordagem. Esclareceu que, quando o réu caiu, ele ficou deitado com barriga para baixo e com os braços contraídos sob o corpo e, como não sabiam o que ele tinha nas mãos, o que, inclusive, poderia ser uma arma de fogo ou arma branca, desferiram alguns golpes com objetivo de virá-lo e para que ele soltasse o que estava segurando, o que depois foi descoberto tratar-se de uma chave. No interior do veículo, sobre o banco traseiro, encontraram uma caixa de papelão contendo cinco tijolos de maconha e cinco porções menores do mesmo entorpecente. Questionado, o réu assumiu a propriedade das drogas, mas não deu outras informações. Antes de ser conduzido à Delegacia, ele foi encaminhado ao Pronto Socorro, onde foi medicado devido a uma lesão na cabeça que sofreu por ocasião da abordagem, já que foi necessário o uso de força física moderada para contê-lo. Informou que o pai do réu compareceu ao local e disse que o veículo, embora havia sido tirado em seu nome (do pai), era de propriedade pelo réu. No mesmo sentido as declarações prestadas extrajudicialmente (fls. 04) e em juízo (gravação) pelo policial militar Marcello de Freitas Bertão, o qual divergiu de seu colega apenas ao afirmar que ele, particularmente, não conhecia o réu anteriormente.

Anoto que os relatos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar suas palavras na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confiram-se alguns julgados:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao

recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressaltados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

Registro que os relatos dos agentes da polícia não foram infirmados pelas demais provas dos autos.

A testemunha arrolada pela defesa, Irineu Luís Andreotta, ouvida em juízo (gravação), nada soube dizer sobre os fatos. Apenas declarou que o réu trabalhou com ele e sempre se mostrou pessoa respeitadora e responsável, ganhando em média de R\$ 1.800,00 a R\$ 2.000,00 por mês. Nunca soube do envolvimento do réu com o tráfico de drogas. Confirmou que ele tinha um carro Citroen.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que o réu transportava em seu veículo, para fins de tráfico e consumo de terceiro, 5 invólucros, na forma de tijolos, contendo maconha, bem como outras 5 porções, na forma de tabletes, da mesma substância, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De fato, sua confissão foi corroborada pelos uníssonos e convergentes depoimentos dos policiais militares no sentido de que as drogas estavam na sua posse, dentro do carro que dirigia.

Confirma a prática delitativa o fato de que o acusado ter agido de forma absolutamente comprometedor quando, durante o transporte do entorpecente, recebeu ordem de parada dos policiais, tendo empreendido fuga até que não mais conseguiu fugir em razão de problemas mecânicos em seu automóvel.

A expressiva a quantidade de entorpecentes apreendida, incompatível a situação de mero usuário, aliada à confissão do réu, não deixa dúvidas de que ele a transportava para entregar a terceiros.

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/06, ficando afastada a tese defensiva de insuficiência probatória.

Passo à individualização das penas.

A quantidade de drogas é expressiva, fugindo à normalidade da espécie e justificando o aumento na primeira fase.

Assim, fixo as penas-base em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Reconheço a agravante da reincidência (condenações definitivas nos processos criminais nº 2212-43.2016, fls. 153 e nº 4252-95.2016, fls. 154) e, por outro lado, a atenuante da confissão.

Como ambas as circunstâncias são consideradas preponderantes, deixo de aumentar ou diminuir as penas na segunda fase, não se justificando o aumento em razão de serem duas as condenações anteriores.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de penas.

Registro que, por expressa disposição legal, a reincidência impede a aplicação do redutor do parágrafo 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06 e, tratando-se de dupla reincidência decorrente de condenações por crimes graves de roubo, impõe a fixação de regime fechado para início do cumprimento da pena corporal, sem possibilidade de substituição por restritivas de direitos ou concessão de sursis, estes também incabíveis em razão da quantidade de pena aplicada, pois indica que o réu vem reiterando na prática de crimes de maior gravidade.

Acrescente-se a isso as graves consequências do delito de tráfico, que, no caso, foi de grande monta e fomenta a prática de vários outros crimes, destrói famílias, vidas e a saúde dos usuários, que dificilmente conseguem se livrar do vício.

Eleição de regime diverso e aplicação de penas substitutivas da corporal, no caso concreto dos autos, impediriam que a pena cumprisse suas funções de prevenção e reprovação de crimes, pois não fariam com que o réu sentisse as consequências de seu grave ato.

Há várias decisões de nossos Tribunais no sentido de que é possível a eleição do regime fechado, sem substituição por restritivas de direitos, no crime de tráfico de drogas se a natureza, a reincidência e as circunstâncias concretas do crime indicarem tratar-se de agente de maior periculosidade.

Confira-se julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Revisão criminal – Tráfico de drogas e Trazer arma consigo sem licença – Art. 33, caput, da lei 11.343/06 e art. 19 da Lei de Contravenções penais – Absolvição quanto ao crime de tráfico – Ausência de decisão contrária à prova dos autos – Robusto conjunto probatório – Narrativas dos policiais militares são seguras, coerentes e indicam o encontro de drogas com o peticionário – Tais depoimentos não devem ser desqualificados, tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa a ele – Ademais, a versão exculpatória do réu restou isolada nos autos – Em sede de revisão criminal, não cabe discutir se a prova era suficiente ou insuficiente ao reconhecimento da culpabilidade do acusado, mas tão somente verificar se a condenação foi contrária à evidência dos autos. E esse não é o caso dos autos, pois a prova colhida no decorrer da instrução resultou suficiente para a prolação de decreto condenatório – Reincidência devidamente demonstrada, o que torna incogitável aplicar o redutor – Regime fechado inalterado, tendo em vista a presença da recidiva do acusado – Pena maior de quatro anos, o que impossibilita a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos – Pedido indeferido”. (TJSP - Revisão Criminal 2031611-39.2020.8.26.0000. 4º Grupo de Direito Criminal. Relator (a): Freitas Filho – j. 29/09/2020) – g.n.

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Apreensão de 200g de cocaína e um revólver calibre 32. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Incabível a absolvição ou desclassificação. Materialidade e autoria indúvidas. Réu detido na posse de chave de veículo automotor, em cujo interior foram encontradas a arma e as drogas. Ausência de justificativa plausível acerca dos fatos. Forma de acondicionamento do entorpecente aponta a traficância. Porte de arma e munições é delito de perigo abstrato. Arma periciada. Potencialidade lesiva atestada. Dosimetria bem realizada. Reincidência impede a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos. Regime fechado decorre do quantum da pena e da biografia penal do acusado, além da gravidade, consequências e hediondez do crime. Recurso não provido". (TJSP - Apelação 0003463-89.2015.8.26.0400. 8ª Câmara Criminal Extraordinária. Relator(a): Carlos Monnerat - j. 05/09/2017) -g.n. Registro que o reconhecimento da reincidência para fins de impedir a concessão de benefícios ao acusado e apená-lo de forma mais grave não fere a coisa julgada, nem constitui "bis in idem", pois não se trata de punir o agente duas vezes pelo mesmo fato.

Como bem ensina Guilherme de Souza Nucci, essa ideia "peca pela simplicidade. O sistema de fixação de penas obedece a outro preceito constitucional, merecedor de integração com os demais princípios penais, que é a individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF)" (CPComentado - RT, 13ª ed., pag. 464).

Ao se reconhecer a reincidência e aumentar a pena do crime em razão dessa agravante ou deixar de aplicar ao réu alguma benesse, o Estado nada mais faz do que punir com maior rigor o agente que, tonando a delinquir, desafia a ordem pública e as leis vigentes, demonstrando, no dizer do professor Nucci, "persistência e rebeldia inaceitáveis para quem pretenda viver em sociedade. Destarte, sofre uma punição mais severa" (obra citada, pag. 464).

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico.

APELAÇÃO CRIMINAL - PENA E REGIME PRISIONAL - Pena fixada com critério e corretamente - Reincidência do réu que inviabiliza a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas - Bis in idem não caracterizado, pois o aumento na segunda etapa e a impossibilidade de aplicação do privilégio na terceira fase são efeitos distintos decorrentes do mesmo instituto - Inviável, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis, por força do disposto nos artigos 44, incisos I e II, e 77, caput, e inciso I, ambos do CP - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Recurso desprovido." (TJSP - Apelação 0003941-43.2015.8.26.0127 - 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Nelson Fonseca Junior - j. 14/09/2017) -g.n.

Pelos mesmos motivos, fica vedado o direito do réu apelar em liberdade, pois necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, diante da ausência de elementos para se verificar as condições econômicas do réu.

Tendo em vista que, no caso dos autos, o veículo foi utilizado como instrumento para o transporte das drogas, pode ser ele confiscado e decretado seu perdimento em favor da União, consoante o disposto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, não se exigindo, nesses casos, habitualidade, nem mesmo que o veículo esteja preparado especificamente para o transporte da droga, conforme tese fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 647 da Repercussão Geral: "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal" (RE nº 638.491/PR. Relator Min. Luiz Fux, Dje. 23/08/2017). Neste sentido há diversos julgados do E. TJSP:

"Apelação. Tráfico de drogas. Recursos da acusação e da Defesa. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação mantida. Pena. Causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006. Impossibilidade. Reconhecimento da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas. Aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas na fração de 2/3. Possibilidade. Substituição da pena privativa de liberdade. Possibilidade. Regime inicial aberto mantido. Perdimento dos bens e valores. Mantido perdimento do veículo e do dinheiro. Instrumento e produto do crime. Restituição somente do telefone celular. Recursos parcialmente providos". (TJSP -Apelação Criminal 1500705-22.2019.8.26.0627. Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Luiz Fernando Vaggione - j. 07/04/2021) - g.n.

"Apelação criminal - Tráfico de drogas - Sentença absolutória Recurso Ministerial, buscando a condenação do réu nos termos da denúncia. Materialidade e autoria comprovadas - Prisão em flagrante delito - Apreensão de 186 porções de cocaína (peso aprox. de 271 gramas) - Depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos entre si, e em relação àqueles prestados perante a Autoridade Policial - Descrição detalhada da prática da traficância pelo acusado - Versão do réu que não restou comprovada nos autos - Condenação como medida de rigor. Dosimetria da pena - Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal - Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes - Na terceira fase, ausentes causas modificativas. Fixação de regime inicial fechado, único compatível com o delito em tela, diante da alta gravidade e reprovabilidade da conduta do réu, em concreto - Impossibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque falta amparo legal, e porque as circunstâncias também não recomendariam a substituição - Tratamento incompatível com os objetivos da Lei de Drogas. Perdimento de bem em favor da União - Veículo utilizado para a prática da traficância de drogas. Recurso Ministerial provido para condenação do réu, nos termos da denúncia. Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente" (TJSP - Apelação Criminal 1500365-60.2019.8.26.0536. Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Ely Amioka - j. 07/04/2021) - g.n.

O C. STJ também já se pronunciou neste sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. TRANSNACIONALIDADE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. QUANTIDADE E